الشهادة

المسألة الأولى

التعريف بالشهادة وسببها ومشروعيتها وطبيعتها

أولاً: تعريف الشهادة

- التعريف في اللغة: تطلق على الخبر القاطع، أو الحضور أو المعاينة.
- التعريف في الاصطلاح اختلف فيه الفقهاء

عند الحنفية: هي الإخبار الصادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

عند المالكية: هي إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه.

عند الشافعية: هي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.

عند الحنابلة: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

فيتضح من التعريفات السابقة؛ أن الشهادة لابد أن تكون:

- عند حاكم أو قاضي عند الحنفية والمالكية.
- بلفظ أشهد أو شهدت، عند الشافعية والحنابلة.
- ولكن جميعهم اتفقوا على أن الشهادة "إخبار بحق للغير على الغير".

ثانياً: حكمة التسمية بالشهادة:

لأنها مأخوذة من المشاهد المتيقنة، وتسمى أيضاً بالبينة، لأن الحقوق تبين بها.

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لرجل سأله عن الشهادة: "ترى الشمس"؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: "على مثلها فاشهد، أو دع".

ثالثاً: مشروعية الشهادة:

يدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والمعقول.

- دليل الكتاب: قوله تعالى "واستشهدوا شهيدين من رجالكم"، "وأشهدوا ذوي عدل منكم".
- دليل السنة: حديث الأشعث بن قيس حيث اختصم مع رجل على بئر فذهبا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينك. قلت يحلف ولا يبالي؟ فقال ﷺ من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك بـ" إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " وجعل النبي ﷺ البينة على الطرف الأضعف مركزاً في الدعوى، حيث قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه".

وقال ﷺ في خطبته: "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه".

- دليل المعقول: فلا يختلف عاقل على أن الحاجة داعية إلى العمل بالشهادة، لإثبات الحقوق.

رابعاً: سبب الشهادة:

يرجع السبب إلى أمرين:

الأول: طلب المدعي؛ لعموم قوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"

الثاني: خوف فوات الحق حسبة لله تعالى؛ لقوله: "كونوا قوامين لله شهداء بالقسط"، "وأقيموا الشهادة لله"

خامساً: طبيعة الشهادة:

الأصل فيها أنها تقوم على الصدق والأمانة سواء في مواجهة مسلم، أو غيره، أو قريب، أو غريب. لقوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله"، ولما سئل النبي ﷺ عن أكبر الكبائر فقال: "الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".

وبناء على ذلك، فإن الشاهد عند شهادته لا يضع في حسبانه مجاملة أحد، أو الانتقام من أحد، بل يقول الحق وما شاهده فقط.

لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"

المسألة الثانية

حكم الشهادة التكليفي تحملاً وأداءً

الشهادة لها مرحلتان:

الأولى: تحمل، وهو التحصيل.

الثانية:أداء، وهو البذل.

أولاً: تحمل الشهادة في الحقوق والحدود

حكم تحمل الشهادة يختلف بحسب نوع المشهود عليه، هل هو حق أم حد.

ولذلك المقصود بالحقوق: هي كل ما يتعلق بمصلحة آدمي كالنكاح والإقرار والقصاص، وسائر عقود المعاملات.

أما المقصود بالحدود: هو كل ما يتعلق بحق الله تعالى، أي مصلحة دينية وليست آدمية، كحد الزنا.

حكم تحمل الشهادة في الحقوق الآدمية:

يختلف حكم تحمل الشهادة باختلاف حكم الإشهاد، هل هو واجب أم جائز؟

- فإن قلنا أن الإشهاد واجب فيكون تحمل الشهادة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
- وإن قلنا أن الإشهاد جائز وليس واجباً فيكون تحمل الشهادة جائزاً أو سنة على الكفاية، إلا إذا انضم إليه ما يوجبه، كالخوف من ضياع الحق.

ويختلف حكم الإشهاد في حقوق الآدميين باختلاف نوع العقد، حسب التفصيل الآتي:

- **عقد الزواج:**

يرى أكثر أهل العلم: وجوب الإشهاد على عقد الزواج، لحديث النبي ﷺ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

ويرى الإمام مالك: الإشهاد ليس واجباً إذا تم الإعلان عنه، وإن لم يعلن فيجب عند الدخول.

ويرى الإمامية: أن الإشهاد ليس واجباً مطلقاً.

- **عقد الطلاق والرجعة:**

يرى أكثر أهل العلم: أن الإشهاد في عقد الطلاق والرجعة سنة.

ويرى بعض المالكية والإمام الشافعي: أن الإشهاد فيهما واجب، ولكنهما يصحان بدونه؛ لعموم قوله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة..... وأشهدوا ذوي عدل منكم"

ويرى بعض الشافعية ومذهب الإمامية: أن الإشهاد في الطلاق واجب ولا يصح بدونه.

- **عقود البيع والمداينات:**

يرى أكثر أهل العلم: أن الإشهاد مستحب؛ لقوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته"

ويرى الظاهرية: أن الإشهاد واجب؛ لظاهر الأمر به في قوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.... وأشهدوا إذا تبايعتم"

حكم تحمل الشهادة في حقوق الله "الحدود": ليس واجباً في ذاته بالإجماع، وإنما هو جائز أو مستحب بحسب النية فيه؛ لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء"، ولقول النبي ﷺ " المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ"

ثانياً: أداء الشهادة في الحقوق والحدود:

يختلف حكم أداء الشهادة في الحقوق وفي الحدود، نبين ذلك فيما يلي:

حكم أداء الشهادة في الحقوق الآدمية:

أجمع الفقهاء على أنها فرض كفاية، بحيث لو قام بها البعض سقط عن الباقيين، وإذا امتنع الجميع أثموا.

أما لو تعينت الشهادة على عدد بلغ نصابها كرجلين، صارت فرض عين عليهما.

الدليل: قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله"، وقوله: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا.

هل يشترط لأداء الشهادة في حقوق الآدميين المطالبة بها؟

- إذا كانت في الديون والديات فلا يجوز التقدم بالشهادة قبل طلبها، لإمكان التسامح والعفو.
- أما إن كانت في الديانات العامة أو الجامعة، كالطلاق والرجعة والرضاع؛ فيجب بذلها حسبة.

لدليل: قول النبي ﷺ "الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم".

حكم أداء الشهادة في الحدود أو حقوق الله:

اختلف الفقهاء في حكم أداء الشهادة في الحدود أو حقوق الله تعالى الخالصة أو الغالبة مثل الزنى والسرقة، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: (الحنفية والمالكية)

قولهم: الشاهد مخير بين أداء الشهادة وعدم أدائه، والترك أولى.

حجتهم: أنه قد يتعارض مقصدان شرعيان: حسبة الشهادة لله، وحسبة الستر، وكلاهما مندوب إليه.

دليلهم: قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله"، قول النبي ﷺ: "من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة".

المذهب الثاني: (بعض المالكية)

قولهم: يحرم أداء الشهادة في الحدود.

حجتهم: أن الشرع أمر المسلم بالستر على نفسه وعلى غيره، فيكون الأداء محرمً.

دليلهم: قوله تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة"، وعن زيد بن سالم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى في عهد النبي ﷺ فجلد، ثم قال: "أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".

المذهب الثالث: (مذهب الحنابلة)

قولهم: أن أداء الشهادة يرجع إلى تقدير الشاهد واعتقاده بتوبة المخطئ أو عدم توبته؛ فإن رأى توبته لم يشهد، وإلا وجب عليه الشهادة.

حجتهم: الجمع بين مقصد الستر وبين مقصد الأمن من إشاعة الفاحشة.

المسألة الثالثة

شروط تحمل الشهادة

يشترط فيها عدة شروط: لكي تفيد علم الشاهد وإحاطته بحمل الشهادة ليقنع القائمين على العدالة:

١- العقل بالإجماع؛ لاستحالة تحمل المجنون شيئاً من العلم.

٢- البصر، عند الحنفية. ويرى الجمهور: جواز شهادة الأعمى فيما يجري فيه التسامع، كالنسب والوفاة والزواج.

٣- العلم بمحل الشهادة بالإجماع؛ لأن العلم هو مناط الشهادة. لدليل ابن عباس أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الشهادة؟ فقال: "هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع".

٤- لا يشترط فيها البلوغ والعدالة والإسلام، لأنها لا تعدوا أن تكون معرفة أو علماً بأمر حدث.

المسألة الرابعة

شروط أداء الشهادة

يشترط في أدائها عدة شروط تحقق مقصودها للعمل بموجبها، وهي أربعة أقسام بحسب مرجعها:

١- شروط ترجع إلى الشهادة.

٢- شروط ترجع إلى المشهود عليه.

٣- شروط ترجع إلى الشاهد.

٤- شروط ترجع إلى النصاب أو العدد في الشهادة.

أولاً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الشهادة نفسها:

١- اتفاق الشاهدين على محل الشهادة، ليتحقق المقصود منها. (تم الإجماع على الشرط)

٢- أن تؤدى الشهادة بلفظ أشهد.

عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية؛ لأنه متبادر إلى الذهن بالأمر بالشهادة.

والأظهر عند المالكية: أنه يكفي ما يدل على حصول علم الشاهد، كقوله: رأيت أو سمعت، ولا يشترط قوله: أشهد.

ثانياً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى المشهود به:

١- أن يكون المشهود به معلوماً، فالشهادة بمجهول لا تقبل. (بالإجماع)

٢- أن يكون المشهود به متقوماً شرعاً، مثل مال أو منفعة لأن بغيره يكون عبث. (بالإجماع)

ثالثاً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الشاهد (أهلية الشاهد)

عشرة ضوابط على التفصيل الفقهي الآتي:

أولاً: العقل (تم الإجماع عليه)

لعجز المجنون عن أداء الشهادة.

ثانياً: بلوغ الشاهد سن التكليف

- يرى جمهور الفقهاء: اشتراط بلوغ الشاهد سن التكليف، فلا تقبل شهادة الأطفال والصبيان؛ لعموم قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم"، ولقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث.....، وعن الصغير حتى يبلغ".

وذلك لأن شهادة غير البالغ لا تلقي قبولاً لفض الخصومات.

- ويرى المالكية والحنابلة في رواية: جواز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا. وذلك على وجه الاستثناء احتياطاً للدماء.

ثالثاً: حرية الشاهد

- يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: اشتراط الحرية للشاهد.

- يرى الحنابلة والظاهرية: عدم اشتراط الحرية في الشاهد، ولكنهم استثنوا الحدود والقصاص، لقيامها على الدرء بالشبهة.

رابعاً: إبصار الشاهد

- يشترط الحنفية والشافعية: أن يكون مبصراً، فلا تقبل شهادة الأعمى لعدم تحقق اليقين فيما شاهده. واستثني الشافعية وزفر من الحنفية على ما يثبت بالسمع كالنسب والزواج، فإنهم أجازوا شهادة الكفيف.

- ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والظاهرية: صحة شهادة الكفيف بحكم عدالته، ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين.

خامساً: نطق الشاهد

- جمهور الفقهاء: يشترط أن يكون الشاهد ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس لعدم استبانة مراده.
- ويرى المالكية: صحة شهادة الأخرس، حال معرفة دلالة إشارته.
- ويرى الحنابلة: صحة شهادة الأخرس، إذا كتبها بخطة، وليس فقط إشارته.

سادساً: ذكورة الشاهد

أ) في الحدود والقصاص

- جمهور الفقهاء: يشترطوا ذكورة الشاهد في الشهادة على الحدود والقصاص دون سائر الحقوق والمداينات. لما عن الزهري أنه قال: "مضت السنة بأنه لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص".
- ويرى الظاهرية: قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص. لقوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"، وفي حديث خروج النبي ﷺ في عيد الأضحى، وقد مر على نساء فأمرهن بالصدقة، وفيه قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"؟ قلن: بلى. أو كما قال رسول الله ﷺ.

حجتهم: الجمع بين عموم الآيتين: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"، وآية: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"

ب) في عقد الزواج

- جمهور الفقهاء: يشترطوا الذكورة في عقد الزواج، فلا تقبل شهادة النساء.

لدليل قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"

- ويرى الحنفية والحنابلة في رواية، والظاهرية: عدم اشتراط الذكورة في الشهادة على عقد الزواج، فتصح شهادة رجل وامرأتان. وزاد الظاهرية جواز شهادة أربع نسوة على عقد الزواج.

وأدلتهم: عموم قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"، وحديث: "شهادة المرأة نصف شهادة الرجل".

سابعاً: انعدام التهمة

- جمهور الفقهاء: يشترطوا انعدام التهمة بين الشاهد والمشهود عليه، سواء كانت بالمحاباة كشهادة الخادم لمخدومة، أو بالانتقام كشهادة من بينهم عداوة.

لدليل: النبي ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"، والغمر هو الحقد، والقانع هو الخادم المنقطع عن الخدمة.

- ويرى الظاهرية: أنه ينظر في العدوان؛ فإن كانت تخرج صاحبها إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته، وإن كانت لا تخرج عداوته فهو عدل تقبل شهادته.

ثامناً: شرط العدالة

يشترط في الشاهد عند أداءه أن يكون عدلاً؛ لأن عدالته أصل في تلقي شهادته بالقبول.

واختلف الفقهاء في تعريف العدالة بين موسع ومضيق، ولكن في الجملة يعنون مستور الحال، وهو الذي لا يجاهر بالإصرار على الصغائر، وعدم العلم بارتكابه كبيرة.

أما الفاسق فلا تقبل شهادته؛ لعموم قوله: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"

ما حكم شهادة الفاسق إذا تاب؟

عند جمهور الفقهاء: إذا تاب الفاسق قبلت شهادته، سواء كانت المعصية من موجبات الحد أم من موجبات التعزير. ولكن الاختلاف الفعلي بين المذاهب من كان عليه حد القذف ثم تاب.

قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "

فما هي آراء الفقهاء في حكم قبول شهادة التائب من خطيئة قذف المحصنات؛ على مذهبين:

المذهب الأول: (جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية)

<u>قولهم:</u> قبول شهادة التائب المحدود في القذف.

<u>حجتهم:</u> عموم قوله تعالى: " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "، فأتى ذلك بعد

النهي عن قبول الشهادة، ويكون المعنى الظاهر: إلا الذين آمنوا فاقبلوا شهادتهم، وليسوا بفاسقين. فهنا القاذف لو تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته.

المذهب الثاني: (الحنفية)

قولهم: عدم قبول شهادة المحدود في قذف حتى وإن تاب.

حجتهم: أن الله تعالى رد شهادته على التأبيد نصاً، وأن الاستثناء الوارد للتائبين يرجع إلى صفة الفسق بشكل عام لأنه أقرب للمذكور، ولا يرجع إلى الشهادة، لأن المحدود في القذف إذا تاب لا يسمى فاسقاً، ومع ذلك فلا تقبل شهادته، وذلك من تمام الحد المنصوص عليه في الآية الكريمة.

تاسعاً: الإسلام في أداء الشهادة على مسلم

اختلف الفقهاء في اشتراط صفة الإسلام للشاهد في النزاعات التي يكون أحد أطرافها مسلماً، ويرجع السبب إلى أربعة أمور:

١- الاختلاف في مفهوم النص المبين لصفة عدالة الشاهد، هل يمنع لغيرهم من الشهادة عليهم أم لا؟

٢- الاختلاف في النص الوارد بشأن قبول شهادة غير المسلم على المسلم، في الوصية في السفر من حيث النسخ وعدمه، وإذا لم يكن منسوخاً فهل هو قاصر على الوصية، أو يتعداها إلى سائر العقود عند الحاجة.

٣- الاختلاف في تكييف الشهادة.

٤- الاختلاف في طبيعة اختلاف الدين، هل هو من أسباب العداوة في الدنيا أم أنه مجرد تنوع عقائد مع اتحاد مصالح.

الأربع أسباب هم محل النزاع ويتم شرح اختلاف المذاهب على أساسهم، ونجمل أقوال الفقهاء في هذه المسألة في ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: (جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية)

قولهم:

عدم جواز قبول شهادة المسلم على غير المسلم بأي حال.

حجتهم:

(١) أن النصوص في الكتاب والسنة ظاهرها يمنع من قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين. قوله تعالى: "وأشهدوا شهيدين من رجالكم" فخرج بذلك غير المسلمين، وقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، وغير المسلم ليس بعدل لعدم إيمانه بالحق، كما أنه ليس منهم.

(٢) قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ....."، منسوخ بقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم".

(٣) أن الشهادة تتضمن نوع ولاية، وهي لا تجوز من غير المسلم على المسلم، لعموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"

(٤) أن اختلاف الدين أمارة ظاهرة على العداوة، وهي تهمة ترد الشهادة، ويدل على ذلك، قوله تعالى: "لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء"، ولقول النبي النبي ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت".

المذهب الثاني: (الحنابلة والظاهرية)

قولهم:

قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية، ولكن بشرط الحاجة كانعدام وجود المسلمين، وهذا ما قال به الحنابلة؛ أما الظاهرية قيدوا بحال السفر فقط.

حجتهم:

أن القرآن الكريم نص صراحة على جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية في السفر، فكان هذا استثناء من حكم الأصل.

لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ"، وهذه الآية نزلت في رجل من بني سهم عندما مات بأرض ليس بها مسلم، انظر ص٣١.

المذهب الثالث: (ابن تيمية وابن القيم)

قولهم: قبول شهادة غير المسلمين وأيمانهم على المسلمين في جميع الحقوق الإنسانية عند الحاجة بالضوابط العامة في الشهود دون أن يكون منها صفة الإسلام.

حجتهم:

(١) أن النصوص المبينة لصفة عدالة الشهود لا تمنع غير المسلمين في الشهادة على المسلمين، فقوله تعالى: "شهيدين من رجالكم"، وقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"؛ خطاب للغالب وليس تقييداً بصفة الإسلام.

وأما العدالة فهي الإنصاف وتكون من المسلم وغير المسلم في المعاملات دون خصوص العقيدة.

(٢) قياس الشهادة على اليمين، فإذا صحت اليمين بالله تعلى من غير المسلمين صحت شهادتهم، حيث أجاز الشافعية والحنابلة لغير المسلم أن يحلف ويكون حنثه بالإطعام والكسوة دون الصوم، وذلك خلافاً للحنفية والمالكية الذين اشترطوا الإسلام لانعقاد اليمين؛ لكونها من الديانات.

ويدل على صحة اليمين من غير المسلم، قوله تعالى: "تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ"، فقد جعل القسم بعد الصلاة لتعظيم اليمين، وقيل أن هذه صلاة العصر، وهو وقت يعظمه أهل الأديان.

كما يدل على صحة اليمين من غير المسلمين إقرار النبي ﷺ بأيمان اليهود في حديث القسامة، حيث حلف لهم اليهود على دم عبد الله عندما قتل واتهم في ذلك يهود خيبر، وهذا دليل على قبول أيمانهم في الإثبات.

(٣) آية المائدة الواردة في قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية في السفر، تشمل الوصية وغيرها من العقود الحياتية، كما تشمل السفر والحضر؛ إذ لا خصوصية في الوصية ولا في السفر، وإنما يرجع الأمر إلى الحاجة والمصلحة حتى لا يضيع حق المسلم إذا لم يشهده سوى غير المسلم.

(٤) أن الشهادة إخبار عن أمر واقع، والخبر مقبول من المسلم وغيره.

وليست الشهادة ولاية، ولو سلمنا بأنها ولاية، فلا مانع أن تكون بين المسلمين وغيرهم في الأموال والمصالح الحياتية، كما في الكفالة والضمان.

وأما قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" فهو متعلق بيوم القيامة؛ لسياق الآية: "فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"

(٥) أن طبيعة اختلاف الدين ترتب تنوعاً في العقائد ولا ترتب عداوة في المصالح الحياتية، لحاجة الناس لبعضهم، ولعموم قوله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

الرأي المختار:

هو المذهب الثالث للإمام ابن تيمية وابن القيم من جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية وفي غيرها من سائر عقود المعاملات في ساحات القضاء ومجالس التحكيم الأهلية.

رابعاً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى نصابها أو عدد الشهود

النصاب العددي في الشهادة يختلف بحسب محل الشهادة، كما يلي:

١- <u>أربعة رجال في الزنى</u> عند أكثر أهل العلم فلا تقبل شهادة النساء فيه؛ لعموم قوله تعالى: "لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء"، وقوله: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدء"، فالمتبادر إلى الذهن

عند إطلاق لفظ الشهداء، أن يكونوا من الرجال.

ويرى الظاهرية قبول شهادة النساء في الزنى وغيره من الحدود، على مبدأ أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.

٢- ثلاثة رجال في شهادة الفقر لمن كان غنياً وذلك عند الحنابلة؛ خلافاً للجمهور.

فتحصل هذه الشهادة إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير لأخذ زكاة.

٣- رجلان فيما سوى الزنا من القصاص وسائر الحدود كالسرقة والقذف.

هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، ويدخل ذلك في كل ما يطلع عليه الرجال مما ليس بمال كالطلاق والرجعة لقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، وفي النكاح قال النبي ﷺ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"

وقال الحنفية: تجوز شهادة رجال وامرأتين فيما سوى الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق.

ويرى الظاهرية: جواز شهادة النساء منفردات في النكاح وغيره، بناءً على قاعدة: "شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل في كل شيء".

٤- رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك في الحقوق المالية كالبيع والحوالة.

وذلك عند الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة،

ويرى الظاهرية: قبول شهادة النساء منفردات، وفقاً لقاعدتهم.

٥- النساء منفردات في الولادة والاستهلال والرضاع وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب بالإجماع؛

واختلف في عدد الشاهدات، على خمسة أقوال:

القول الأول: (مذهب الحنفية)

تقبل شهادة امرأة واحدة في الولادة سواء كانت طبيبة أم غيرها.

لدليل: عن حذيفة أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة.

القول الثاني: (رواية عن أحمد، الحسن البصري، ابن عباس)

تقبل شهادة امرأة واحدة إن كانت قابلة وإن لم تكن فلا تقبل إلا مع غيرها.

القول الثالث: (مالك، والرواية الثانية عند الحنابلة)

تقبل شهادة امرأتين في الولادة ونحوها على الأقل، لأنهن لما قمن في انفرادهم مقام الرجال وجب أن يقمن في العدد مقام الرجال، وأكثر عدد الرجال اثنان فوجب ذلك للنساء.

القول الرابع: (روي عن أنس، وحكي عن عثمان البتي)

تقبل شهادة ثلاثة نسوة في الولادة ونحوها على الأقل، لأن الله تعالى ضم شهادة المرأتين إلى الرجل في الموضع الذي لا ينفردن فيه، فيجب أن تستبدل المرأة بالرجل في الموضع الذي ينفردن فيه فيصرن ثلاثاً.

القول الخامس: (قول الشافعي، وروي عن عطاء)

تقبل شهادة أربع نسوة في الولادة ونحوها على الأقل، لأن الله حين أجاز الشهادة انتهى بأقلها وهم شاهدين رجلين أو شاهد وامرأتين، فأقام الثنتين مقام الرجل، فإذا جعلوا المرأة تقوم مقام الرجل، فيجعلون كل امرأتين تقومان مقام الرجل، فبذلك لم يجز إلا أربع نسوة، وهذا المعنى أجمع عليه المسلمون.

٦- <u>رؤية الهلال.</u>

- اشتراط رجل واحد في رؤيته وهو أحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية إن كان بالسماء علة من غيم أو غبار.

لدليل: ابن عمر أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.

- وذهب المالكية والقول الثاني عند الشافعية والحنابلة إلى اشتراط شاهدين في ثبوت رؤية الهلال، وبه قال الحنفية في حال الصحو، لدليل: أن النبي ﷺ قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا"

٧- تقبل شهادة الطبيب الواحد في الشجاج، والبيطار في عيوب الدواب (المالكية والحنابلة)

المسألة الخامسة

حكم أخذ الأجرة على الشهادة

اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: (جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ووجه الحنابلة)

قولهم: أخذ جواز الأجرة على الشهادة عند تحملها وأدائها.

حجتهم: عموم قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد"، وقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"

المذهب الثاني: (الحنفية والحنابلة في المشهور)

قولهم: تحريم أخذ الأجرة على حمل الشهادة وأدائها إن عينت عليه.

حجتهم: عموم قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله"، فأجر الشهادة على الله.

المذهب الثالث: (قول بعض الشافعية ورواية ثالثة للحنابلة)

قولهم: جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً حتى ولو لم يكن في تحملها أو في أدائها كلفة.

حجتهم: أن إنفاق الإنسان على عياله فرض عين، والشهادة فرض كفاية، وقياساً على أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة.

الرأي المختار:

يحق لكل مكلف في هذه المسائل أن يختار الرأي الذي تستريح إليه نفسه، مراعياً في ذلك قوة الدليل، ومقاصد الدين من إقامة العدل، وعدم المساس بالسيادة القانونية والقضائية.

القضاء

المبحث الثاني

التعريف بالقضاء وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

المسألة الأولى

تعريق القضاء وبيان مشروعيته

أولاً: تعريف القضاء

- التعريف في اللغة: يطلق على معانٍ كثيرة كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه، قال تعالى: "فقضاهن سبع سماوات في يومين"، أي أراد قطعهن وأحكم خلقهن وفرغ منهن.
- التعريف في الاصطلاح اختلف فيه الفقهاء.

١- الأحناف: هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل.

٢- المالكية: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.

٣- الشافعية: هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. أي بالحق

٤- الحنابلة: هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به.

- رغم اختلاف التعريفات، فهي متفقة في كون القضاء يظهر حكم الحق في نظر القاضي، ويلزم المتخاصمين به.

والإلزام بحكم القاضي لا يكون إلا بعد رفع الخصومة إليه، حيث عرف الأمير اليمني القضاء بأنه: "إلزام ذي الولاية بعد الترافع".

ثانياً: مشروعية القضاء

من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

١- دليل الكتاب: قوله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله"، وهذا أمر من الله لنبيه ﷺ أن يحكم في خصومات الناس بما أنزل الله من أحكام، وكذلك الأمر لمن يلي أمر الأمة بعد النبي ﷺ.

وقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"

٢- دليل السنة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ"

وقوله ﷺ: "إذا حكَم الحاكمُ فاجتَهَد ثمَّ أصاب فله أجرانِ وإذا حكَم فاجتَهَد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ"

٣- دليل الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية القضاء، والحكم بين الناس في خصوماتهم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مشروعية تنصيب القضاء على بيل الوجوب؛ لعدم قيام مصالح الناس إلا به.

وذهب بعض القدرية والخوارج وأبو بكر الأصم، أن تلك المشروعية على سبيل الجواز، لإمكان استقامة الناس بدون قضاء.

٤- دليل المعقول: هو أن الإنسان اجتماعي بطبعه، والعقل يقتضي تحقيق العدل وحفظ الحقوق لمنع الظلم والفوضى. ووجود نظام قضائي يردع الجرائم ويحفظ النظام الاجتماعي ضروري. فالقضاء يطبق القوانين الشرعية، مما يحقق الاستقرار والأمن للمجتمع.

المسألة الثانية

أحكام القضاء التكليفية

أولاً: الحكم التكليفي لاختياروقبول القضاء

الفرض التكليفي للقضاء يختلف بين الحاكم والأفراد، جهتي الاختيار والقبول.

أ) جهتي الاختيار؛ هم الحاكم والأفراد.

ب) جهة القبول من حيث الأفراد؛ قد يكون فرض عين أو فرض كفاية.

إذا نظرنا للحاكم، فهو مُلزم، وفرض عينٍ عليه بتعيين قاضٍ مؤهل أو تولي القضاء بنفسه، ولا يجوز أن يترك المجتمع دون قضاء.

أما بالنسبة للأفراد الصالحين المؤهلين للقضاء، فقبولهم قد يكون فرض عين إذا لم يكن هناك من يصلح غيرهم، أو فرض كفاية إذا كان هناك عدة مؤهلين، بمعني أن الشرع يطلبه من مجموع المكلفين وليس من كل فرد. فإذا قام بعض الصالحين بالقضاء، يسقط الواجب عن الباقين. أما إذا لم يقم أحد بهذا الواجب، يأثم جميع القادرين الذين علموا بالحاجة وتركوا الواجب عمدًا.

وأشار ابن قدامة إلى أن القاضي قد لا يكون مُلزمًا بالقبول إذا كان هناك مخاطر شخصية أو ظلم من السلطان.

ثانياً: حكم الأولى في شأن الصالحين لتولي منصب القضاء

هناك ثلاثة مذاهب رئيسية حول حكم الأولى في قبول منصب القضاء:

المذهب الأول: استحباب القبول لمن عرض علي

- القائلون: عبد الله بن مسعود، عقبة بن عامر، أحد القولين عند الحنفية.

- حجتهم: العمل القضائي له فضل عظيم لأن القاضي ينصر المظلوم، ويأمر بالمعروف، ويحقق العدل في المجتمع، وللقاضي أجرًا، حتى لو أخطأ، لأنه اجتهد في حكمه.

وجاء في حديث ابن مسعود (لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إليَّ من عبادة سبعين سنة)،

وحديث عمرو بن العاص، حيث "جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

اقض بينهما يا عمرو. قلت: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: "وإن كان، قلت: فإذا قضيت بينهما، فما لي؟ قال: "إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت وأخطأت فلك حسنة.

المذهب الثاني: الكراهة عند وجود آخرين يصلحون له

- القائلون: أبو حنيفة، الشافعي، ظاهر كلام الإمام أحمد، ابن عمر، أبو قلابة.
- حجتهم: في العمل القضائي مخاطرة كبيرة لأنه يتطلب دقة عالية في الحكم، واحتمال الوقوع في الظلم، وبالتالي يكون عرضة لتحمل الوزر إذا لم يؤد الحق فيه.

وكان السلف والفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة يخشون من تولي القضاء خوفًا من الوقوع في الخطأ، فكما قال ابن قدامة "كان يقال أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهية"، وأيضاً في حديث عثمان ابن عفان، عندما أراد تولية ابن عمر القضاء فأبى.

وحديث النبي ﷺ: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين"، فيدل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه.

المذهب الثالث: يختلف باختلاف الحال

- القائلون: بعض المالكية، الشافعية، الحنابلة (قول أبي عبد الله بن حامد).
- حجتهم: إذا كان القاضي من أهل العدالة والاجتهاد، ويمكنه القيام بالواجبات القضائية بكفاءة، فيجوز له قبول المنصب أو الاعتذار عنه.

أما إذا كان الشخص ليس معروفًا ولكنه مؤهل، فقبول القضاء يكون مفضلًا لأنه يحقق النفع للمجتمع.

وإذا كان الشخص مشهورًا بالعلم والفتوى، فقد يكون الأولى له أن يشتغل بالعلم والتعليم بدلاً من القضاء. وإذا كان الشخص يخشى الفتنة على نفسه أو على المجتمع، فإن قبول القضاء قد يكون واجبًا لتجنب الفتنة وتحقيق الاستقرار.

ثالثاً: حكم طلب القضاء

١- الكراهة:

قال ابن قدامة في "المغني": يكره للإنسان طلب القضاء لأن النبي ﷺ: "من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده".

والنبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".

وأيضاً عن النبي ﷺ قال لأبي ذر: "إنك ضعيف، وأنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها".

٢- اجتناب الولاية:

النووي في "شرح صحيح مسلم" يقول: لا يُولّى من سأل الولاية لأنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة.

والصنعاني في "سبل السلام" يوضح: نهى النبي ﷺ عن طلب الإمارة لأن النفس تتبع الأغراض الفاسدة، ولا يوثق بحسن العاقبة.

٣- واجب طلب القضاء:

بعض المالكية، كما في حاشية الدسوقي: طلب تولي القضاء واجب لمن توفرت فيه شروط القضاء إن خاف ضياع الحق.

ابن فرحون في "تبصرة الحكام": طلب القضاء يعتريه الأحكام التكليفية الخمسة حسب الظروف.

- الأحكام التكليفية:

أ) الواجب: إذا كان من أهل الاجتهاد ولا يوجد قاضٍ آخر يصلح.

ب) مستحب: إذا كان عالمًا خامل الذكر، غير معروف فيطلب القضاء لنشر العلم ونفع الناس به.

ج) حرام: إذا كان جاهلًا أو فاسقًا، لا تتوفر فيه شروط القضاء.

د) مكروه: إذا سعى لتحصيل الجاه أو الاستعلاء، ويوجد من هو أصلح منه.

هـ) مباح: إذا كان فقيرًا ويسعى لسد حاجته.

هذا ويجوز للحاكم اختيار القاضي الأصلح من أهل الأمانة والعلم ويجبرهم على القضاء إذا أبوا، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما دعي سعيد بن عامر الجمحي.

رابعاً: حكم تولي القضاء لغير الصالحين

يحرم على الحاكم اختيار غير الصالحين لتولي القضاء مع وجود الصالحين، كما يحرم على غير الصالح قبول المنصب؛ ويجب على الحاكم البحث عن أصلح الناس، استدلالاً بحديث النبي ﷺ: "من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله تعالى منه فقد خان الله وخان رسوله، وخان جميع المؤمنين".

كما أن الشخص غير المؤهل يحرم عليه قبول المنصب، لحديث النبي ﷺ: "القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة...". ولأن من لا يُحسن القضاء لا يمكنه تحقيق العدل، مما يؤدي إلى الظلم المحرم.

المسألة الثالثة

أحكام القضاء العامة

أولاً: أركان القضاء

- الركن في اللغة هو الجانب القوي أو الناحية القوية، وما تقوى به من ملك وجند وغيره، وبذلك فسر قوله تعالى: "فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ" (الذاريات: ٣٩).

ويجمع الركن على أركان وأركن.

- الركن في الاصطلاح عند جمهور الفقهاء: هو ما لا بد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء كان جزءًا منه أو مختصًا به، وهو بذلك رديف الشرط.

ويرى الحنفية التفريق بين الركن والشرط. فالركن عندهم هو ما لا بد منه وكان داخلاً في الماهية، فهو جزء من حقيقة الشيء لا يوجد إلا به. أما الشرط فهو ما لا بد منه وكان خارجًا عن الماهية.

- **أركان القضاء خمسة:**

وهي: القاضي، حكم القضاء، الحق المقضي به، المقضي عليه، والمقضي له. ونوجز بيان ذلك فيما يلي:

١-لقاضي: وهو الشخص الذي عينه الحاكم للفصل في الدعاوى والخصومات.

٢-القضاء: وهو ما ينطق به القاضي من حكم لحسم النزاع وقطع المخاصمة.

٣-المقضي به: وهو الحق الذي هو محل كلام القاضي.

- هذا الحق إما أن يكون حقًا لله محضًا كالعبادات.

- أو حقًا للعبد خالصًا كالأموال بين الناس[١].

- أو حقًا مشتركًا بين الله تعالى وبين العبد، وحق الله فيه غالب كالأعراض[٢].

- أو حقًا مشتركًا بين الله تعالى وبين العبد وحق العبد فيه غالب كالدماء التي فيها قصاص[٣].

٤-المقضي عليه: وهو من يحكم القاضي ضده، أو من يستوفى منه الحق.

٥-المقضي له: وهو من يحكم القاضي لصالحه، أو من يستوفي الحق له.

في حقوق العباد المحضة أو الغالبة، يشترط للمحكوم له أن يدعي الحق المحكوم به، فلا يحكم القاضي بحق لم يطلب.

أما حقوق الله المحضة أو الغالبة، فإن المحكوم له هو الشرع، أو الحق العام، أو حق المجتمع، فيحكم القاضي نيابة عن المجتمع دون طلب أحد منه.

ثانيًا: رزق القاضي وأجرته

الرزق غير الأجرة. الرزق في اللغة هو العطايا والمنح المنقطعة أو الجارية، أما الأجر فهو عوض العمل أو المنفعة.

الرزق عند الفقهاء، كما عرفه ابن عابدين في "حاشيته": "ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية

---

[١] قال جل شأنه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ (النساء : ٢٩).

[٢] فرغم أنها حق للعبد إلا أن الضرر على المجتمع واقع، ولذلك لا تسقط بالعفو عند الجمهور.

[٣] قال تعالى: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ (الإسراء : (٣٣(

مشاهرة أو مياومة".

الأجر عند الفقهاء، كما ذكره ابن قدامة في "المغني": "كلُّ ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون عوضًا في الإجارة".

يتضح أن الفرق بين الرزق والأجر عند الفقهاء يعتمد على طبيعة العلاقة بين طرفي المعاملة.

إذا كانت تعاقدية، يكون ما يأخذه العامل أجرًا وتجري فيه المشارطة.

وإذا كانت تكليفية بحكم الولاية، يكون ما يأخذه العامل رزقًا ويكون إذعانًا من الولي، ولا يخضع إلا لحد الكفاية الإنساني.

- **اختلف الفقهاء في حكم منح القاضي رزقًا أو اشتراطه أجرًا مقابل عمله.**

- سبب الاختلاف في حكم رزق القاضي يعود إلى أن عطايا بيت المال مقيدة بحال الاحتياج والفقر، فلا يجوز منحها لغير المحتاج.

- وسبب الخلاف في حكم أجر القاضي يعود إلى أن الأجر في شئون الدنيا وليس في الطاعات، كما أن الأجر يكون في عمل معلوم لمنع النزاع، وهذا غير متحقق في عمل القاضي.

١-رزق القاضي:

- اتفق الفقهاء على جواز منح القاضي رزقًا يحقق له وأسرته حد الكفاية إذا كان من أهل الحاجة، أما إذا كان القاضي غنيًا، اختلف الفقهاء في حكم إعطائه هذا الرزق.

المذهب الأول: جواز منح القاضي ما يكفي من الرزق من بيت المال

- القائلون: جمهور الفقهاء؛ الحنفية في أحد القولين، الإمام مالك وبعض أصحابه، الشافعية في قول أبي بكر الشاشي شيخ الشافعية في عصره، الحنابلة في المذهب، القاضي شريح، ومحمد بن سيرين.- حجتهم:

١- ما ذكره السمناني الحنفي: الرسول صلى الله عليه وسلم رزق عتاب بن أسيد أربعين أوقية في السنة عند ولايته لمكة.

٢- أن عمر بن الخطاب: كتب إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل في الشام أن يرزقوا القضاة من مال الله ليكون

لهم قوة.

٣- ما ذكره ابن قدامة: عمر بن الخطاب رزق زيد بن ثابت وشريح كل شهر مائة درهم، وبعث رزقًا لابن مسعود وعمار.

٤- القرافي: عمر بن عبد العزيز دفع مائة دينار سنويًا للقاضي وكان يوسع على عماله.

٥- رفع الضرر: إعطاء القاضي رزقًا يرفع عنه كلفة معيشته ومستلزمات عمل.

٦- حفظ نزاهة القضاء: الرزق من بيت المال يحفظ نزاهة القضاء ويمنع الطمع في أموال المتخاصمين.

٧- خدمة الناس: القاضي في خدمة الناس، فرزقه من بيت المال يضمن استمرار القضاء وعدم تعطيله.

المذهب الثاني: عدم جواز منح الرزق للقاضي إذا لم يكن محتاجاً

- القائلون: الحنفية في القول الثاني، المالكية في قول المازري وغيره من بعض المالكيين، الشافعية في المذهب، الحنابلة في رواية حكاها أبو الخطاب.

- حجتهم:

١- الرزق لا يُعطى إلا للمحتاجين، والإنفاق من بيت المال يجب أن يكون في المصالح، ولا مصلحة في دفع الرزق للقاضي المتبرع.

٢- عدم إعطاء الرزق للقاضي يزيد من هيبته ويعزز تعظيم الناس لمقامه.

الرأي المختار: هو اختيار الدولة لنظام الرواتب أو الأجور النظامية للقضاة، وهو ما لا يسع المسلم خلافه، وفقًا للقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف".

٢- أجر القاضي:

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء بحيث يكون للقاضي أجرًا مشروطًا ومعلومًا، وليس رزقًا ممنوحًا بحد الكفاية، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: عدم جواز الاستئجار على القضاء

- القائلون: مذهب الجمهور: الحنفية، المالكية، الشافعية في المذهب، الحنابلة في المشهور، مسروق بن

الأجدع، عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن.

قال القرافي في "الذخيرة": "اتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء".

- حججهم:

١- ما ذكره ابن قدامة في "المغني": عمر بن الخطاب قال: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا".

٢- القضاء من القربات والطاعات، فهو شبه الصلاة التي يتقرب بها دون أجر.

٣- القضاء ليس عملاً نيابياً عن غيره حتى يأخذ عليه أجرًا، بل يقضي القاضي باجتهاد نفسه، فهو يعمل عند نفسه ولا يأخذ الإنسان من نفسه أجرًا

٤- القضاء عمل غير معلوم القدر، فلا يجوز أن يكون محلاً للإجارة، إذ يشترط لصحة الإجارة العلم بالمعقود عليه.

٥- جواز أخذ القاضي الرزق لا يعني له جواز أخذ الأجرة، كما في القضاء والشهادة والإمامة[٤].

<u>المذهب الثاني:</u> جواز الاستئجار على القضاء

- القائلون: وجه عند الشافعية: القاضي حسين المروزي.

- حججهم:

١- القضاء من الأعمال الفنية المادية كالتعليم والتطبيب، وليس من القربات المحضة، فجاز الاستئجار عليه.

٢- القياس على الرزق، فإذا جاز منح القاضي رزقًا فلا مانع من إعطائه أجرًا.

٣- أجر القاضي ليس على العمل الاجتهادي، بل نظير احتباس الوقت.

[٤] يقول ابن قدامة في "المغني": "ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز الأجرة بدليل القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة

لمذهب الثالث: كراهة أخذ الأجر المشروط على القضاء

- القائلون: قول ابن مسعود والحسن البصري، واختاره الإمام أحمد.
- حجتهم: الخروج من الخلاف في حكم الأجر على القضاء؛ خاصة وأنه يمكن اكفاء القاضي بالرزق من بيت المال.

الرأي المختار: الذي عليه الدولة ونظامها؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف".
فيجوز إعطاء القاضي أجرًا مشروطًا في عقد إجارة كامل الأركان، باعتبار القضاء عملًا فنيًا ماديًا وليس قربة محضة.

ثالثًا: إلزام القاضي أن يحكم بمذهب معين أو بالقانون.
اختلاف الفقهاء في حكم اشتراط القاضي بالحكم وفق مذهب معين أو القوانين الوضعية يرجع إلى أن القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز إلزام المجتهد بغير اجتهاد نفسه.

ثالثًا: إلزام القاضي أن يحكم بمذهب معين أو بالقانون

اختلف الفقهاء في حكم الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين عند تقليده، كأن يشترط عليه أن لا يحكم إلا بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة أو بالحكم وفق التقنينات الحديثة المعروفة بالقوانين الوضعية. يعود سبب اختلاف الفقهاء إلى كون القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز إلزام المجتهد بغير اجتهاد نفسه.

المذهب الأول: عدم جواز الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين
- القائلون: جمهور الفقهاء؛ متقدمو الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية.
وإذا حدث الاشتراط كان الشرط باطلًا.

- حجتهم:

١- عموم قوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" (ص: ٢٦). والحق لا يتعين في مذهب معين، وقد يظهر الحق في غيره.

٢- قول ابن تيمية: قهر الناس على رأي معين يؤدي إلى التفرق والاختلاف.

٣- القاضي من أهل الاجتهاد، ويحرم قهر المجتهد على غير اعتقاده.

وقبول القاضي لهذا الشرط يعني ارتضاءه للتقليد، ولا يجوز للمجتهد التقليد.

سؤال: هل عقد تولية القاضي يبطل لبطلان هذا الشرط؟

- جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: بطلان عقد التولية لبطلان الشرط.

- الحنفية والظاهرية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة: صحة عقد التولية وبطلان الشرط، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".

المذهب الثاني: جواز الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين

- القائلون: متأخرو الحنفية: نص عليه ابن عابدين في "حاشيته".

- حجتهم:

١- عموم قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" (المائدة: ١)، وقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا" (الإسراء: ٣٤).

٢- حديث النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم"، مع زيادة: "إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".

٣- القضاء عمل فني، وإلزام القضاة بالحكم بالقانون المختار يحقق العدل أكثر من تفويضهم لاجتهاداتهم المتباينة.

الرأي المختار: ما ذهب إليه المتأخرون من الحنفية إلى جواز تقييد القاضي عند تقليده أن يحكم بمذهب معين أو قانون معين، لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، ولتحقيق العدل بين الناس بتوحيد القضاء، وفقًا لاختيار الدولة ونظامها؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف".

المسألة الرابعة

شروط الصلاحية لتولي القضاء

نظرًا لأهمية القضاء وعظم خطره، وضع الفقهاء عدة ضوابط لتولي القضاء لضمان النزاهة والهيبة. واتفقوا على شروط مثل البلوغ، العقل، واعتماد تعيين الحاكم لأهليته، واختلفوا في شروط أخرى مثل الإسلام، الذكورة، سلامة الحواس، القدرة على النطق، والعدالة.

أولًا: تولية المرأة أو غير المسلم القضاء على المسلمين

اختلف الفقهاء حول اشتراط الذكورة والإسلام في القاضي، ويرجع سبب الاختلاف في شرط الذكورة إلى الاختلاف في إلحاق القضاء بالولاية العامة أو العمل الفني كالإفتاء أو الشهادة التي هي إخبار، على أربعة مذاهب.

المذهب الأول: عدم جواز تولية المرأة أو غير المسلم القضاء مطلقًا ولا ينفذ حكمها إن وقع.

- القائلون: الجمهور؛ المالكية، الشافعية، الحنابلة.

- حجتهم:

١- عموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا" (النساء: ١٤١) والقضاء من أعظم السبل، فيمنع على غير المسلمين للمسلمين، وعموم قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء" (النساء: ٣٤)، فلا ينبغي أن تكون المرأة في وظيفة تكون فيها قيمة على الرجل.

٢- حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (البخاري).

٣- غير المسلم لا يعرف أحكام الإسلام، والمرأة ناقصة عقل عن الرجل، مما لا يؤهلها للقضاء[٥].

المذهب الثاني: عدم جواز تولية غير المسلم القضاء على المسلمين، وجواز تولية المرأة في بعض القضايا

- القائلون: الحنفية: يجوز للمرأة تولي القضاء في القضايا التي تقبل شهادتها فيها، مثل الأموال والعقود.

- حجتهم:

١- الشهادة فرع عن القضاء، وفيها معنى الولاية، فوجب إلحاقها به، فكل من جازت شهادته جاز قضاؤه.

٢- المرأة لا تجوز شهادتها في الحدود والقصاص، فلا يجوز قضاؤها في ذلك.

المذهب الثالث: يرى عدم جواز تولية غير المسلم القضاء على المسلم مطلقا، ويجوز أن تتولى المرأة القضاء في كل شيء، حتى الحدود والقصاص.

- القائلون: ابن جرير الطبري، وإليه ذهب الظاهرية ونصره ابن حزم.

- حجتهم:

١- عموم قوله تعالى : "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" النساء : (١٤١)، فهذا يمنع بظاهره تعيين غير المسلم قاضيا.

٢- عموم ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وهذا أصل في صحة ولاية المرأة كصحة ولاية الرجل.

٣- حكى أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء، وهي امرأة من قومه، ولاية السوق، وهي من الولايات العامة.

٤- قوامة الرجل تعني مسؤوليتهم في خدمة وحماية مصالح النساء، وليست سيادتهم أو تسلطهم عليهن.

---

[٥] ويدل على نقص عقل المرأة عموم قوله تعالى: أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى" البقرة : (٢٨٢)

النبي ﷺ قال: "النساء شقائق الرجال".

٥- حديث أبي بكرة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" يفسر على الخلافة العظمى أو تفويض الغير دون مشاركة، أو خاص ببنت كسرى لأن أباها مزق كتاب النبي ﷺ، فدعا عليه النبي أن يمزق ملكه.

المذهب الرابع: يرى جواز تولية غير المسلم أو المرأة القضاء، إن ولاهما سلطان ذو شوكة[٦]، وينفذ قضاؤهما.

- القائلون: بعض الشافعية، كما حكاه الشيخ زكريا الأنصاري، والشربيني الخطيب.

- وحجتهم:

١- اجتهاد السلطان :السلطان من أهل الاجتهاد وله أن يُنشئ رأيًا فقهيًا غير مسبوق. وعموم الأدلة الآمرة بالسمع والطاعة له، قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، وحديث النبي ﷺ عن عبادة بن الصامت: "دعانا النبي ﷺ فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان" (الشيخان).

٢- رفض التمييز: منع تعيين القضاة المؤهلين علميًا لكونهم من النساء أو غير المسلمين يُعتبر ظلمًا وعنصرية، ويؤدي إلى تعطيل المصالح وضياع الحقوق، وهو مخالف لمبادئ الدين في إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد؛ والقضاة في الدولة الحديثة يحكمون بالقانون بعد دراسة وموافقة مجتمعية، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم.

الرأي المختار: طاعة ولي الأمر فيما له من حق الاجتهاد؛ للقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف فضلا عن مراعاة المصلحة المرسلة التي تدور في الزمان والمكان والحال، وفي ظل الدولة الحديثة التي تقوم على المواطنة بدستور يسوي - بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

[٦] الحاكم القوي (أو السلطان) الذي يمتلك السلطة والنفوذ.

وعلى هذا القول بجواز تولية الدولة مواطنيها من غير المسلمين أو النساء القضاء، والذي قال به بعض الشافعية، هو الرأي الذي ينبغي الالتزام به لضمان النظام العام ومنع الفوضى، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ عن عبادة بن الصامت بشأن البيعة بالسمع والطاعة.

أسباب ترجيح القول بصحة تولية المؤهلين علميًا القضاء من غير المسلمين والنساء:

١- استدلال غير صحيح: الاستدلال بمنع غير المسلمين تولي القضاء بقول الله "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا" خارج عن محل النزاع، فالآية تتحدث عن الآخرة وليس شؤون الدنيا، ومقصد القضاء هو إقامة العدل، والعدل صفة إنسانية فطرية لا تتطلب الإسلام أو الذكورة، والنبي ﷺ أثبت صفة العدل لغير المسلمين، والقرآن أذن بقبول شهادة غير المسلمين في وصايا المسلمين[٧]، ووصفهم بأنهم أهل عدل.

٢- أقوال كبار الفقهاء: صحة تعيين القضاة من النساء هو قول بعض كبار الفقهاء مثل ابن جرير الطبري وبعض الشافعية ومذهب الظاهرية. والنبي ﷺ نزل على رأي أم سلمة في صلح الحديبية ولم يصفه بالنقصان[٨]، وأثبت أن النساء شقائق الرجال (أحمد، أبو داود، الترمذي).

ثانياً: تولية فاقد بعض الحواس القضاء

نتكلم عن تولية فاقد بعض الحواس القضاء، في العناصر الأربعة الآتية:

١- التعريف بسلامة الحواس

الحواس في اللغة هي: مشاعر الإنسان، وحواس الإنسان هي المشاعر الخمس: الطعم، الشم، البصر، السمع، واللمس.

المقصود بسلامة الحواس عند الفقهاء: سلامة الجسم في السمع والبصر والنطق، وقد اقتصر الفقهاء على سلامة هذه الحواس للحاجة إليها في إقامة العدل بين الناس.

---

[٧] قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (المائدة: ١٠٦).

[٨] أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلح الحديبية: قوموا فانحروا، ثم احلقوا، فما قام منهم رَجُل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، قلم يقم منهم أحد، ثم دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، ففعل، وفعل أصحابه من بعده.

أما سلامة سائر أعضاء الجسم في غير تلك الحواس الثلاث، كسلامة الأذنين واليدين والرجلين، فإنما تعتبر استحبابًا لا لزومًا؛ فالهيئة في ولاية القضاء مستحبة لا مستحقة؛ لأن المقصود أن يكون القاضي قادرًا على مهام وظيفته بالسمع والبصر والكلام، وإن كانت السلامة في تلك الأعضاء تضفي عليه كمالًا وهيبة.

٢- اشتراط سلامة الحواس في القاضي

إن فقد البصر، والسمع، والكلام يحول دون القيام بمهام القضاء، أما فقدان حاسة واحدة من البصر أو السمع أو الكلام، فقد اختلف الفقهاء في حكم تولية القضاء مع هذا الفقد.

٣- فقد حاسة البصر في القاضي

المذهب الأول: اشتراط سلامة حاسة البصر في القاضي، وإن طرأ عليه العمى بطلت ولايته.

- القائلون: وهو مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، المالكية في قول، الشافعية في الأصح، والحنابلة.

- حجتهم: أن كفيف البصر لا يفرق بين الطالب والمطلوب، ولا يعرف المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له.

- أجيب على ذلك: بأن الكفيف يستطيع أن يفرق بين هذه الحالات جميعهم، بالاستعانة بمستشار مؤتمن.

المذهب الثاني: عدم اشتراط سلامة البصر لصلاحية تولي القضاء، فتصح تولية كفيف البصر.

- القائلون: المالكية في المشهور، الظاهرية، الإمامية، وبعض الشافعية.

- حجتهم: أن شعيب عليه السلام كان أعمى، كما أن كفيف البصر تصح إمامته[٩]، وإذا صحت إمامته صحت توليته للقضاء؛ وشهادته مقبولة عند كثير من الفقهاء.

- أجيب على ذلك: ابن قدامة في "المغني" يرد على الادعاء بأن شعيب عليه السلام كان أعمى، ويقول إن هذا غير صحيح وغير مثبت. كما يوضح أن الشرع السابق ليس ملزمًا لنا بالنسبة لإمامة ابن أم مكتوم في الصلاة، ويوضح أن هذا يختلف عن القضاء لأنه لا يحتاج لرؤية المأمومين، ويشير إلى أن رواية استخلافه

[٩] حيث استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم إماما في الصلاة على المدينة المنورة وكان أعمى.

ضعيفة.

الرأي المختار: الالتزام بقرار ولي الأمر[١٠]، فقد وضعت الدولة ضوابط العمل القضائي وشروط صلاحية توليه بما يضمن إقامة العدالة ويراعي المصالح المرسلة والتطور الحضاري في حقوق الإنسان.

٤- فقد حاسة السمع في القاضي:

المذهب الأول :اشتراط سلامة السمع في القاضي، وإن طرأ عليه الصمم بطلت ولايته.

- القائلون: جمهور الفقهاء: الحنفية، الشافعية في المعتمد، الحنابلة.

- حجتهم: أن الأصم لا يستطيع التفريق بين الإقرار والإنكار، ليميز الحق من الباطل.

ودليل عن علي أن النبي ﷺ: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضيا بعد".

المذهب الثاني: عدم اشتراط سلامة السمع في القاضي، فتصح ولاية الأبكم.

- القائلون: المالكية في المشهور، الشافعية في وجه، الظاهرية، الإمامية.

- حجتهم: صحة إمامة الأصم في الصلاة، فتصح ولايته للقضاء.

الرأي المختار: ليس له محل، بعد أن وضعت الدولة ضوابط العمل القضائي بما يضمن صلاحية الاختيار ونزاهته، ويراعي المصالح المرسلة في حقوق الإنسان.

ثالثاً: تولية فاقد العدالة القضاء

اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة لصحة ولاية القضاء.

المذهب الأول :العدالة شرط لصحة تولي القضاء واستمراره، فلا تصح ولاية الفاسق، وإن حكم ينفذ حكمه إلى حين عزله، حتى لا تتعطل مصالح الناس.

- القائلون: جمهور الفقهاء: الحنفية في قول، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية.

- حجتهم: أن القضاء حارس للعدالة، وفاقد الشيء لا يعطيه. لعموم قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن

[١٠] عملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف."

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا..." (الحجرات: ٦).

ويرى بعض المالكية بطلان حكم القاضي الفاسق ولا ينفذ حجمه.

المذهب الثاني :العدالة ليست شرطًا لصحة تولي القاضي، فتصح ولاية الفاسق في القضاء.

- القائلون: الحنفية في الأصح عندهم.

- حجتهم: طاعة ولي الأمر الذي عينه، وقياسًا على الشهادة التي تصح من الفاسق عندهم.

الرأي المختار: ليس له محل، فقد وضعت الدولة ضوابط العمل القضائي بما يضمن صلاحية الاختيار ونزاهته، وتتبع السيرة الذاتية للمرشحين للقضاء، ومتابعة مسيرتهم المهنية والمجتمعية اللائقة التي ترفعهم فوق مستوى الشبهات.

المسألة الخامسة

تأثير الأحكام القضائية الحقوقية على الأحكام الديانية

تبحث هذه المسألة الفقهية عن تكييف الحكم القضائي الحقوقي في ميزان الدين. كما وقع الخلاف في تكييف الحكم الإفتائي، هل هو من إنشاء المفتي باجتهاده أو من اكتشافه لمراد الله، وقع الخلاف أيضًا في الحكم القضائي الحقوقي[١١]، هل هو منشئ للحق بسلطة القاضي أو كاشف عن الحق في علم الله.

يعتمد القاضي عند الحكم على الأدلة مثل الأوراق الثبوتية والشهود، أو على قناعته واجتهاده. قد تكون الأدلة كاذبة أو اجتهاد القاضي غير مصيب. في جميع الأحوال، يجب إنفاذ حكم القاضي لحسم النزاع، لكن بالنسبة للخصوم، هل يستحلون حكم القاضي ديانةً إذا علموا زور الشهادة أو اعتمد القاضي على رأي فقهي يرونه فاسدًا؟ أم يكون حكم القاضي باطلاً ديانةً إذا كان مبنيًا على شهادة زور أو رأي فقهي مخالف؟

وهي مسألة معتمدة على تكييف الحكم القضائي فقهياً.

[١١] وهو الصادر بحق آدمي يتعلق بمال ، أو شفعة، أو استحقاق وظيفة، أو العزل منها، أو زواج، أو طلاق، أو نحو ذلك.

تكييف الحكم القضائي متردد بين فقهين:

- الفقه الأول: الحكم القضائي كاشف عن الحق الذي في علم الله، وليس للمحكوم له استحلال ما بني على شهادة زور أو خطأ القاضي.
- الفقه الثاني: الحكم القضائي منشئ للحق كالعقود، وينفذ ديانةً، ويجب استحلاله، حتى لو بني على شهادة زور أو اختلاف مذهبي.

الفقهاء تناولوا مسألة تكييف الحكم القضائي وما يترتب عليه من أثر ديني، بتفريقهم بين:

- الحكم القضائي الصادر عن أدلة كاذبة،
- الحكم القضائي الصادر عن اجتهاد يراه المحكوم له باطلاً.

النوع الأول: الأحكام القضائية الحقوقية المبنية على الأدلة الكاذبة

تتعلق هذه الأحكام بالحقوق المبنية على أدلة تتعلق بالعقود أو الفسوخ، مثل الطلاق، الزواج، البيع، أو فسخ عقد إيجار، استنادًا إلى شهادة زور. في حال صدر الحكم القضائي النهائي بإجراءات سليمة، فهل يكون نافذاً ديانةً وقضاءً أم فقط في الظاهر؟

المذهب الأول: الحكم القضائي كاشف عن الحقيقة التي هي في علم الله

- القائلون: المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، أصحاب أبي حنيفة الثلاثة (أبو يوسف، محمد، زفر).
- حجتهم: أن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. حديث النبي ﷺ: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحَن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" (الشيخان).
- الخلاصة: الحكم الصادر بشهادة زور يكون باطلاً عند من يعلم كذب الشهادة، ويجب عليهم التناصف بما يرضي الله، ولا يستحلون المحكوم به.

المذهب الثاني: الحكم القضائي منشئ للحقوق، وليس كاشفاً الذي هو عند الله.

- القائلون الشعبي، أبو حنيفة.

- حجتهم: حكم الحاكم حجة شرعية منشئة للعقود والفسوخ؛ لأن القضاء يهدف لقطع المنازعة، كما أن تفريق اللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب يقيناً ويؤيد هذا قصة هلال بن أمية عندما لاعن زوجته[١٢]، وحديث "شاهداك زَوْجَاكِ".

- الخلاصة: الحكم القضائي ينفذ ديانةً وقضاءً، حتى لو كان مبنيًا على شهادة زور، ويجب استحلاله.

اعتراضات على المذهب الثاني:

١- الحكم القضائي كاشف وليس منشئًا للحقوق، وقد يخطئ القاضي ويصيب في هذا الكشف.

٢- حديث "شاهداك زَوْجَاكِ" لا حجة فيه لأنه أضاف التزويج للشاهدين.

٣- أن الفرقة في اللعان بسبب الوصول إلى أسوأ الأحوال وليس بسبب صدق الزوج.

الرأي المختار: يمكن الجمع بين المذهبين باعتماد حجية الأحكام القضائية الحقوقية، مع ضرورة التنازل عن المحكوم به في حال مساسه بحق الغير، مثل صحة عقد زواج بشهادة زور بدون رضا الطرفين.

فيجب على الطرف الذي لا يرضى بالحكم أن يعترض عليه، ولا يحل للطرف الآخر الاحتجاج به ديانة.

---

[١٢] أن النبي ﷺ فرق بين هلال وبين امرأته باللعان وقال : "أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيئ العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو الشريك بن سحماء"، قال أنس: فأنبئتُ أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين – أي على الوصف المكروه – وتبين الأمر على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن موجودة، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة وأمضاها.

النوع الثاني: الأحكام القضائية الحقوقية المبنية على اجتهاد القاضي الذي يراه المحكوم له فاسدًا

أمثلة على ذلك:

- **الشفعة للجار:**

الحنفية أجازوا الشفعة، لدليل: "جار الدار أحق بالدار".

جمهور الفقهاء يرون عدم ثبوت الشفعة للجار[١٣]؛ لما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم...".

تكييف المسألة: إذا اجتهد القاضي وحكم بالشفعة للجار وكان هذا الجار لا يعترف بها، فهل يجوز له ديانة استحلال الشفعة بالجوار لأن القاضي حكم له بها؟ أم يحرم عليه العمل بالحكم الذي يخالف مذهبه الفقهي؟

- **صحة الزواج بدون ولي:**

الحنفية يرون صحة الزواج إذا زوجت المرأة الرشيدة نفسها من زوج كفء.

جمهور الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة) يرون بطلان الزواج لعدم وجود ولي.

تكييف المسألة: إذا قضى القاضي الحنفي بصحة الزواج من المرأة الرشيدة التي زوجت نفسها من زوج كفء، فهل يجوز للزوج مالكي المذهب أو غيره استحلال هذا الزواج بناءً على حكم القاضي؟**مذهبان:**

المذهب الأول: الأحكام القضائية منشئة للحق

- القائلون: جمهور الفقهاء (الحنفية، المالكية، الشافعية في وجه، الحنابلة).

- القول: الأحكام القضائية الحقوقية الصادرة بمذهب القاضي واجتهاده، حتى وإن كانت مخالفة لمذهب الخصوم، تنشئ الحق المحكوم به وتنفذ في الظاهر والباطن، أي قضاء وديانة، ولا توصف بخطأ أو صواب.

---

[١٣] لعدم الضرر بسبب قسمة الحدود، وأن الشفعة إنما تكون في الملك المشاع وليس في المقسم؛ لما أخرجه الشيخان – واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

- الحجة: أن هذه الأحكام الحقوقية مبنية على حق القاضي في الاجتهاد فيها، ولا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله.

المذهب الثاني: الأحكام القضائية لا تلزم الخصوم إذا خالفت مذهبهم

- القائلون: رأي بعض الشافعية مثل أبو إسحاق الإسفراييني، أبو حامد الغزالي.
- القول: الحكم القضائي الحقوقي المخالف لمذهب الخصوم الفقهي لا يلزمهم، فلا ينفذ باطناً أي ديانة، ولا يستحل المحكوم له المحكوم به على خلاف مذهبه المعتقدي.
- الحجة: أن المحكوم له من أهل الاجتهاد، أو من أهل الالتزام بفتوى معينة، ويراها الحق، وما عداها باطل، فلا يستحل شيئًا يعتقد بطلان فقهه

الرأي المختار: في النظام القضائي الحديث، الذي يعتمد على قانون متفق عليه مسبقًا، تم تجاوز الخلافات الفقهية القديمة. الدستور يكفل حرية الاعتقاد ويمنع إلزام أي شخص بقبول حق يراه حرامًا بناءً على معتقده. إذا صدر حكم يخالف المذهب الفقهي للمحكوم له، يمكنه رفضه، ولكن إذا كان الحكم لصالح طرف آخر، يجب الامتثال له للحفاظ على حقوق الآخرين.

المبحث الثالث

التعريف بالتحكيم وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

يهدف هذا المبحث إلى تعريف التحكيم وبيان أحكامه الفقهية العامة في المسائل الأربع التالية:

المسألة الأولى

تعريف التحكيم وبيان أنواعه وأهميته وحكمه الفقهي

أولاً: تعريف التحكيم في اللغة وفي الإصلاح:

- في اللغة: التحكيم هو تفويض الحكم إلى الغير ليحكم، ومصدره هو حكم تحكيمًا.

- في الاصطلاح: التحكيم هو تولية الخصمين حكمًا أو أكثر ليس قاضيًا؛ ليحكم بينهما.
وفي مجلة الأحكام العدلية: "التحكيم هو اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما للفصل في خصومتهما ودعواهما".

ثانياً: أنواع التحكيم

١. تحكيم قضائي: يكون بطلب القاضي ويكون قرار المحكمين استشاريًا للقاضي.

٢. تحكيم عرفي أو أهلي: باختيار أطراف الخصومة بعيدًا عن ساحة القضاء. عند إطلاق مصطلح التحكيم، غالبًا ما يُقصد التحكيم العرفي.

ثالثاً: أهمية التحكيم

يختلف باختلاف نوعه:

١- التحكيم القضائي: يساعد في دراسة القضية بدقة وعرضها على القاضي، ما يعزز فهمه للقضية.

٢- التحكيم العرفي: ينهي الفصل في الخصومات سريعًا وبدون تعطيل إجراءات التقاضي الرسمي، ويحقق تراضي الأطراف. يخفف التزاحم على القضاء الرسمي ويعزز فرص التصالح بين الأطراف.

ومع أهمية التحكيم العرفي، تكمن خطورته في العزوف عن القضاء الرسمي، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة أو طول أمد التقاضي الرسمي. ومع ذلك، فإن التحكيم يخفف الزحام على القضاء الرسمي، لكنه يظل قضاءً عرفيًا يحتمل المحاباة لأحد الأطراف.

رابعاً: حكم التحكيم الفقهي

اختلف الفقهاء في مشروعية التحكيم العرفي على مذهبين:

المذهب الأول: عدم مشروعية التحكيم العرفي

- وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية.

- حجتهم أنه يخشى من التحكيم ترك القضاء بعلمه واجتهاده، إلى تحكيم العوام والجهلة بغير الحق والعدل.

المذهب الثاني: مشروعية التحكيم العرفي في الجملة

- وهو قول جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم.

- حجتهم مستمدة من:

١. دليل الكتاب:*عموم قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير" (النساء: ١٢٨)، و"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها" (النساء: ٣٥).

٢. دليل السنة: مثل تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في أمر بني قريظة.

٣. دليل المعقول: التحكيم يحقق مقاصد في فض الخصومات بالتراضي، فهو نحو من الصلح، وكما قال تعالى: "والصلح خير" (النساء: ١٢٨).

ولا يخشى من التحكيم الحكم بغير ما أنزل الله أو تحكيم الجهلة؛ لأن التحكيم يكون بالتراضي غالبًا، والتراضي هو حكم الله في المعاملات، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء: ٢٩).

وقد وقع التحكيم بين بعض كبار الصحابة دون نكير، كما تحاكم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم.

المسألة الثانية

الفرق بين التحكيم والقضاء

تذكر الفروق بين التحكيم والقضاء في سبعة عناصر، وهي الولاية، والمشروعية، والأهلية، والتهمة، والمحل، والرجوع فيه، ونقضه.

أولاً: الولاية

١. القضاء: ولايته عامة من الإمام أو الرئيس، فهو قضاء رسمي.

٢. التحكيم: ولايته خاصة من أطراف الخصومة، فهو قضاء عرفي.

ثانياً: المشروعية

١. القضاء: مجمع على مشروعيته في الجملة، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.

٢. التحكيم: فيه خلاف فقهي، حيث أجازه الجمهور؛ للتخفيف على القضاء، ومنع جوازه بعض الحنفية (بعض الحنفية والشافعية)؛ خشية من تحكيم الجهال وترك العلم في القضاء.

ثالثاً: الأهلية

١. القضاء: يشترط في القاضي شروط تؤهله لولاية القضاء العامة، ومن أهمها العلم بمتطلبات القضاء.

٢. التحكيم: اختلف الفقهاء في شروط المحكم:

- المذهب الأول: (جمهور الفقهاء).

يجب أن يتصف المحكم بأهلية القاضي وشروطه؛ لأنه في حكم القاضي

- المذهب الثاني: (بعض الشافعية والحنابلة).

لا يشترط في المحكم كل صفات القاضي، بل تكفيه الشروط التي تمكنه من فصل الخصومة بتراضي أطرافها

رابعاً: التهمة

١. القضاء: لا يجوز للقاضي أن يحكم في خصومة يتهم فيها.

٢. التحكيم: اختلف الفقهاء في اشتراط عدم تهمة المحكم:

- المذهب الأول: (جمهور الفقهاء، بعض الحنفية، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة).

لا يجوز تحكيم الخصم وغيره ممن يتهم

- المذهب الثاني: (القول الثاني عند المالكية والشافعية والحنابلة).

يجوز تحكيم الخصم وغيره ممن يتهم؛ لأنه قضاء عرفي قائم على التراضي

خامساً: محل التحكيم

١. القضاء: يفصل في كل نزاع يعرض عليه.

٢. التحكيم: محل خلاف، ونجمله في أربعة مذاهب:

- المذهب الأول: (الشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام أحمد).

يجوز التحكيم في كل ما يجوز فيه القضاء حتى الحدود والقصاص

- المذهب الثاني: (ابن عرفة المالكي).

يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه

- المذهب الثالث: (جمهور الفقهاء الحنفية، المالكية في القول الثاني، والشافعية والحنابلة في المشهور). يجوز التحكيم في كل الأقضيات عدا الحدود والقصاص، وما فيه حق الله كالطلاق واللعان والنسب

- المذهب الرابع: أجاز أبو حنيفة في رواية التحكيم في القصاص، وأجاز السرخسي الحنفي التحكيم في القذف.

سادساً: الرجوع عن الحكم

١. القضاء: لا يجوز الرجوع في حكمه لحسم مادة النزاع، ولحماية هيبة القضاء.

٢. التحكيم: محل خلاف، ونجمله في ثلاثة مذاهب:

- المذهب الأول: يجوز الرجوع في التحكيم قبل صدور الحكم من المحكم (جمهور الفقهاء).

- المذهب الثاني: يجوز الرجوع في التحكيم قبل صدور الحكم وبعده (بعض الشافعية والحنابلة).

- المذهب الثالث: لا يجوز الرجوع في التحكيم بحال (ابن الماجشون المالكي).

سابعاً: نقض الحكم

١. القضاء: محل إجماع في عدم نقض حكمه إلا إذا خالف نصاً قاطعاً. أما في المسائل الاجتهادية، فلا يجوز نقضها عند جمهور الفقهاء، ولكن يجوز نقضها عند الحنفية، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة.

٢. التحكيم: محل خلاف:

- المذهب الأول: إذا رفع أحد المتنازعين في التحكيم أمره للقضاء، لا يجوز نقض التحكيم إلا بما ينقض به قضاء القضاة (جمهور الفقهاء).

- المذهب الثاني: التحكيم لا يلزم القاضي، فله أن يعده كأن لم يكن (الحنفية).

المسألة الثالثة

صور التحكيم

يقع التحكيم بثلاث صور بحسب موضوع النزاع: مالي، عائلي، ديني.

أولاً: التحكيم للصلح المالي (التعويضي)

- يصح الصلح المالي من كل من يقدر عليه وله المكانة الأدبية عند المتخاصمين.

- يشترط ألا يكون المحكم قريباً لأحد الخصمين لمنع المحاباة، إلا أن بعض المالكية والشافعية والحنابلة أجازوا تحكيم من يتهم.

- الصلح المالي مشروع بالتراضي، واستشهد الفقهاء بأدلة من القرآن والسنة:

<u>دليل القرآن:</u>

- قال تعالى: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" (النساء: ١١٤).

<u>دليل السنة:</u>

- أخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً."

- أخرج الطبراني عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا."

- أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، وارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما وقال لكعب: "ضع من دينك هذا" وأومأ إليه أي الشطر، قال: "فعلت يا رسول الله". قال: "قم فاقضه".

- أخرج الشيخان عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: "والله لا أفعل"، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين المتالي على الله لا يفعل المعروف"؟ فقال: "أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب."

ثانياً: التحكيم للصلح العائلي (الأسري)

- يشترط أن يكون المحكم من الأقارب في الأسرة أو من في حكمهم.

- يعتمد التحكيم العائلي على مراعاة قيمة الكبار في العائلة كضمانة للصلح.

- إذا لم يوجد من أهل القرابة الأدنين، يؤخذ بالأباعد وفقاً للأقرب فالأقرب.

- اختلف الفقهاء في سلطة الحكمين في النزاع الزوجي وفي جهة تنصيب الحكمين.

(١) سلطة الحكمين في النزاع الزوجي:

- المذهب الأول: لهما الجمع والتفرقة بين الزوجين (قول جمهور الفقهاء).

- حجتهم: أخرج عبد الرزاق عن عثمان بن عفان أنه بعث حكمين وقال لهما: "إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقا".

- المذهب الثاني: لهما الجمع فقط بين الزوجين (الحسن البصري، قتادة، زيد بن أسلم، أحمد بن حنبل، داود الظاهري).

- حجتهم: عموم قوله تعالى: "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" (النساء: ٣٥).

(٢) جهة تنصيب الحكمين في النزاع الزوجي:

- المذهب الأول: منصوبان من جهة الحاكم (جمهور الفقهاء).

- حجتهم: عموم قوله تعالى: "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" (النساء: ٣٥).

- المذهب الثاني: وكيلان من جهة الزوجين (أبو حنيفة، الجديد للشافعي).

- حجتهم: حاجة الحكمين لمعرفة ما يحمله كل زوج من صاحبه لتقريب وجهات النظر.

ثالثاً: التحكيم للصلح الديني (كفارة صيد المحرم)

التحكيم للصلح الديني يصح من كل من يوصف بالعدالة من المسلمين، ويستند إلى عموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون" (المائدة: ٩٥-٩٦).

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العمد والخطأ في قتل صيد الحرم سواء؛ لكن العمد معه الإثم والخطأ لا إثم فيه.

- الظاهرية وبعض الفقهاء قالوا إنه ليس على المخطيء في صيد المحرم شيء؛ عملاً بظاهر الآية الكريمة: "ومن

قتله منكم متعمداً".

والفقهاء قد اختلفوا في تفسير هذه الآية كيف يكون الحكم بالمثل من النعم، وكيف يكون التخيير:

على ثلاثة مذاهب:

١. المذهب الأول: التفصيل في نوع الصيد (جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة):

- <u>المثلي</u>: الجاني يُخير بين ثلاثة أشياء:

- ذبح المثل من النعم في الحرم والتصدق به على مساكين الحرم.

- تقييم المثل دراهم وشراء طعام يتصدق به على مساكين الحرم.

- صيام يوم عن كل نصف صاع (٦٠٠ جرام تقريباً) من الطعام.

- غير المثلي: يجب فيه قيمته، ويتخير بين:

- شراء طعام يتصدق به على مساكين الحرم.

- صيام يوم عن كل نصف صاع (٦٠٠ جرام تقريباً) من الطعام.

٢. المذهب الثاني: تقدير قيمة الصيد نقداً بتقويم رجلين عدلين (الحنفية):

- إذا بلغت القيمة هدياً يذبح في الحرم.

- شراء طعام والتصدق به على المساكين.

- صيام يوم عن كل نصف صاع من الطعام.

٣. المذهب الثالث: المتعمد لقتل الصيد مخير بين ثلاثة أشياء (الظاهرية):

- إهداء مثل الصيد من النعم.

- إطعام مساكين (أقلهم ثلاثة).

- صيام يوم عن كل شبعة إنسان.

صفة الحكمين في تقدير صيد المحرم:

- قال تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة" (المائدة: ٩٥).

- العبرة بالعدالة الظاهرة، وهل يشترط في هذين الحكمين أو أحدهما ألا يكون قريباً للمحرم المحكوم عليه بالجزاء: مذهبان للفقهاء:

- المذهب الأول: يشترط عدم صلة القرابة بالمحرم المحكوم عليه بالجزاء (جمهور الفقهاء).

- المذهب الثاني: يشترط فقط صفة العدل، فيصح تحكيم الأقارب والأدنين (الظاهرية).

المسألة الرابعة

لزوم التحكيم ونقضه

أولاً: لزوم التحكيم

اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية التحكيم في مدى لزوم حكمه بعد صدوره على مذهبين:

١. المذهب الأول: يرى أن التحكيم ملزم بنفس الحكم (الحنفية القائلين بالتحكيم، المالكية، الشافعية في الأظهر، والحنابلة).

- دليل الكتاب: عموم قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" (النساء: ٣٥)، "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: ١)، و"وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (الإسراء: ٣٤).

- دليل السنة: أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي شريح هاني بن يزيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، وحديث "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون".

- دليل المعقول: أن المحكم بمثابة الوكيل المفوض، وكل من جاز حكمه لزم حكمه كالقاضي.

٢. المذهب الثاني: يرى أن التحكيم ليس ملزماً بنفس الحكم، وإنما يلزم بتراضيهما بعد الحكم (القول الثاني عند الشافعية اختاره المزني، ووجه عند الحنابلة).

- حجتهم: أنه لو ألزمنا الخصمين بحكم التحكيم لكان عزلاً للقضاة، واعتبر رضاهما في اختيار الحكم ولزوم حكمه.

ثانياً: نقض التحكيم بالقضاء

اختلف الفقهاء فيما يجب على القاضي في حال التجاء أحد الخصمين إليه بعد صدور حكم المحكم المختار منهما على مذهبين:

١. المذهب الأول: يرى أنه يلزم على القاضي إنفاذ حكم المحكم المختار وعدم نقضه لمجرد أنه حكم تحكيم، إلا أن يكون مستحقاً للنقض موضوعياً، كمخالفته للنظام العام (الجمهور: المالكية، الشافعية، والحنابلة).

- حجتهم: عموم الأمر بالوفاء بالعقود، والتحكيم من تلك العقود.

٢. المذهب الثاني: يرى أنه من حق القاضي نقض حكم التحكيم في حال مخالفته مذهبه في إصدار الأحكام، ومن حقه عدم نقضه (الحنفية).

- حجتهم: سيادة القضاء على التحكيم، والعمل على توحيد أحكام الأقضية، وعدم تمكين الأحكام العرفية أو الأهلية أن تخرج عن سلطان القضاء.

ثانياً

كتاب الصيد والذبائح

مقدمة

الذبائح تحتل أهمية كبيرة في حياة المسلم حيث يتبع المسلم أحكام دينه المتعلقة بالذبح الشرعي.
الذبح الشرعي له كيفية معينة توضحه النصوص الشرعية والفقهاء، ويتم في حالات الاختيار والاضطرار.

تطوروسائل الذبح والصيد:

مع التطور الصناعي، استُخدمت آلات حديثة في الذبح مثل الذبح الآلي والصعق الكهربائي، ووسائل الصيد مثل البنادق والمسدسات والحقن المسمومة. يجب على المسلم معرفة كيفية التذكية الحديثة وموافقتها للشريعة.

الباب الأول

باب الذبائح

تعريف الذبائح

- لغة: الذبائح جمع ذبيحة، والذبح: مصدر ذَبَحْتُ الشاة.

- شرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي.

الألفاظ ذات الصلة:

- التذكية:

في اللغة: ذبح الحيوان.
في الاصطلاح: السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً.

حكم الذبح

- اشترط الفقهاء لحل أكل الحيوان التذكية الشرعية إلا ما استثناه الشارع كالسمك والجراد.

الأدلة:

- القرآن: "إلا مَا ذَكَّيْتُمْ" (المائدة: ٣)

- السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُل."

- الإجماع: نقله غير واحد من أهل العلم.

حكمة مشروعية الذبح

- أن الحرمة في الحيوان المأكول، أنه ما زال به الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، والشرع ورد بإحلال الطيبات وإزالة الدم المسفوح بالذبح أو النحر؛ وحرمت الميتة لأن الدم المسفوح قائم فيها.
قال تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"

- ومن الحكمة أيضاً: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وتمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع، وإكرام الله للإنسان بإباحة إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته.

إعداد الطالب/ عمر حورس